

1501937-31.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se abstêm de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à "lei do silêncio" e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501937-31.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501937-31.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2167454/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 18621645 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

2940/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2167454 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

2940/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAS DA SILVA MORAES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Jonathas da Silva Moraes dando-o como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, pois, no dia 21 de junho de 2021, por volta das 17h30, no bairro Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca, ele guardava, no interior da sua residência e para fins de mercancia, 215 gramas de maconha, 35 gramas de crack e 52 gramas de cocaína, quando foi surpreendido por ação da Polícia Militar (fls. 209/211).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 22 de junho de 2021 (fls. 99/103).

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar, ocasião em que, em síntese, suscita a ilicitude das provas decorrentes da violação de seu domicílio (fls. 252/330).

As alegações de vício processual e os pedidos de expedição de requisições judiciais

foram indeferidos pelo Juízo (fls. 352/354).

A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2021 (fl. 386) e o acusado foi citado (fl. 408).

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado, que negou a prática delitiva.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da pretensão punitiva estatal (fls. 415/416), ao passo que a Defesa, preliminarmente, suscita a nulidade decorrente da violação do domicílio, que contaminaria a prova dela decorrente, motivo pelo qual pleiteia a absolvição (fls. 421/435).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelos laudos de constatação preliminar e definitiva de substância entorpecente (fls. 14/17 e 200/202) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por seu turno, a autoria também é certa e repousa sobre o ora réu.

Com efeito, os policiais militares Evandro Amaral de Lima e Rafael Braguini de Camargo, quando ouvidos em Juízo, basicamente ratificaram as declarações que já haviam prestado à autoridade policial (fls. 04 e 05). Disseram, em síntese, que na data dos fatos receberam denúncia anônima de que o ora réu estaria embalando entorpecentes em sua residência para fins de distribuição, razão pela qual diligenciaram até o local e vislumbraram, por cima do muro dos fundos do imóvel, que faz divisa com um terreno baldio, o acusado manuseando as substâncias entorpecentes, as quais estavam dispostas sobre uma mesa, na área externa do imóvel. Narraram que de pronto invadiram o imóvel e realizaram a apreensão da droga, assim como de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) portados pelo réu.

Por ocasião de seu interrogatório, o acusado refutou a prática delitiva. Aduziu que estava no seio de seu domicílio, cuidando de seu pai, quando foi surpreendido pelos policiais militares, os quais o algemaram e o agrediram.

Ocorre que a detida análise dos elementos informativos e probatórios carreados nos autos permite inferir que a negativa trazida pelo réu se mostra insulada, pois não é minimamente corroborada por documentos, testemunhas ou qualquer outra notícia formalmente inserida no caderno processual – além do que exige pressupor que as drogas apreendidas foram criminosamente plantadas pelos agentes públicos em seu desfavor, tudo, frise-se, sem qualquer base probatória.

Lado outro, os testemunhos dos policiais militares são firmes, uníssonos, detalhados e coesos. Conquanto não sejam dotados de presunção processual de veracidade nem possuam valor probatório superior às demais provas admitidas no campo do processo penal, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão não podem ser indistintamente desconsiderados tão somente pela natureza da função que exercem, sobretudo quando coesos e uniformes, como no caso. Ademais, não se pode olvidar que nas ações penais lastreadas em autos de prisão em flagrante corriqueiramente as únicas testemunhas são exatamente os policiais responsáveis pela prisão, especialmente em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se abstêm de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à “lei do silêncio” e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, confunde-se com o mérito. Ausência de prova do prejuízo. Absolvição.

Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime para o de porte para uso próprio. Penas inalteradas. Artigo 41 da Lei de Drogas.

Afastamento. Réu não colaborou com as investigações. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500606-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020) Apelação Criminal - TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de drogas e circunstâncias da prisão - Reprimenda. Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga que não pode ser considerada expressiva - Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500097-75.2019.8.26.0610; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Morro Agudo - Vara Única; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020) No caso, não obstante a Defesa suscite que o acusado é perseguido pelos policiais militares e por um deles inclusive ameaçado, a versão - não rara em processos criminais - é despida de maiores e mais precisos detalhes e elementos, de modo que a impugnação defensiva se mostra despida de elementos objetivos que possam colocar em dúvida a imparcialidade dos agentes públicos e a veracidade dos seus depoimentos.

É pouco crível, de mais a mais, que policiais militares transportem 303,67 gramas de drogas, entre maconha, cocaína e crack com o fim de violar o domicílio alheio e forjar flagrante - tudo durante à luz do dia.

Nessa linha, a variedade de drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha), a forma de armazenamento e acondicionamento das substâncias, a apreensão de considerável quantia de origem lícita não esclarecida, e os antecedentes do acusado, que já foi penalmente responsabilizado por tráfico de drogas, permitem concluir que o material tóxico não era destinado ao consumo pessoal, e sim à comercialização. Incabível, destarte, a desclassificação da imputação penal.

No mais, não se sustenta a tese defensiva de nulidade das provas coletadas em razão da violação de domicílio do acusado. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão paradigmática, dotada de repercussão geral, fixou parâmetros para que seja considerada válida a entrada em domicílio sem mandado judicial:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,

devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) - GRIFEI

Destarte, de acordo com a decisão colacionada, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. In casu, a ação policial se adequou ao decidido pelo STF. Isso porque os policiais militares, depois de receberem denúncia anônima, verificaram a procedência da informação e constataram, por sobre o muro da residência do réu, o manuseio de vultosa quantidade de entorpecentes. Tão somente de vislumbrarem a ocorrência de crime permanente, cuja consumação se protraí no tempo e permite a prisão em flagrante a qualquer momento, é que os agentes públicos ingressaram no domicílio do réu.

Nesse sentido, é o entendimento fixado pelo E. TJSP em recentíssimos julgados: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares. Crime permanente indicando situação de flagrância apta a autorizar a pronta ação da Polícia, independentemente de mandado, sem se desprezar o fato de o corréu E. haver franqueado o acesso dos policiais ao imóvel. Inteligência dos artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal. Inexistência de ofensa ao princípio da correlação diante do pedido de absolvição formulado pelo Promotor de Justiça em alegações finais. Nulidade inexistente. Matérias rejeitadas. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão parcial do corréu E. Relatos seguros e coesos dos policiais militares, que apreenderam considerável quantidade de droga e apetrechos relacionados ao espúrio comércio. Delito que admite coautoria ou participação. Condenação mantida. Penas-base acima do piso em face de circunstâncias desfavoráveis representadas por antecedentes desabonadores com relação ao corréu R. e acentuada culpabilidade (artigo 42 da Lei de Drogas). Multirreincidência de R., corrigido erro material representado por apontamento de uma das condenações pretéritas atinente à agravante em pauta. Quadro negativo inconciliável com o privilégio descrito no artigo 33, § 4º, daquela mesma Lei Extravagante, a par de obstaculizar a substituição das corporais por restritivas de direitos providência também colidente com o montante das penas. Regime prisional fechado único adequado ao crime de natureza hedionda, sem se ignorar a existência de circunstâncias adversas e a recidiva de R. igualmente incompatíveis com retiro menos severo. Recursos improvidos, com correção de erro material. (Apelação Criminal nº 1501431-93.2019.8.26.0530, Sertãozinho, rel. Farto Salles, j. 24/06/2021).

APELAÇÃO. Atos infracionais equiparados aos crimes previstos no artigo 33, caput, e 35, c.c. 40, inciso VI, todos da lei n. 11.343/2006. Inexistência de nulidade na ação policial, porque acobertada por hipótese expressamente permitida pelo inciso XI, do artigo 5º, da Constituição Federal. Diante da situação fática-probatória dos autos, verifica-se que não se tratou de mera intuição dos policiais, uma vez que havia elementos que caracterizavam a suspeita de flagrante delito no interior do domicílio. Sentença que, ao contrário do alegado nas razões recursais, apresenta fundamentação idônea, baseada em análise acurada da prova dos autos. Recurso ao qual se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 1500280-40.2020.8.26.0439; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Pereira Barreto - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

"Habeas corpus" - Tráfico de drogas - Alegação de que as provas foram obtidas ilicitamente, mediante violação de domicílio - Pedido de concessão de ordem para trancar a ação penal e nulificar o feito, com a consequente soltura do paciente - Não acolhimento - Ausência de constrangimento ilegal - Inteligência do art. 5º, XI, da CF, que dispensa consentimento do morador e ordem judicial para o ingresso em domicílio alheio nos casos de "flagrante delito" - Tráfico de drogas nas

modalidades "guardar" e "ter em depósito" - Crime permanente - Possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP) - Existência de fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais na residência do paciente - Precedentes - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057567-

23.2021.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021)

Não se vislumbra, assim, afronta ao disposto no art. 5º, XI, da CF, e aos paradigmas fixados pelos Tribunais Superiores no tocante ao ingresso em domicílio sem mandado.

Assim, é de rigor afastar as alegações de nulidade da prova coletada e de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. O conjunto de elementos informativos e probatórios carreado nos autos - formado substancialmente pelos testemunhos dos policiais militares é válido e hábil a formar o convencimento do julgador.

Destarte, tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório, aplicação do princípio do in dubio pro reo ou mesmo desclassificação. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, conclui-se que a natureza e a quantidade das substâncias traficadas são circunstâncias desfavoráveis, tendo em vista a diversidade de drogas apreendidas em poder do acusado (crack, cocaína e maconha) e a considerável quantidade total de entorpecentes, o que denota a maior gravidade do comportamento e justifica o incremento da pena-base. A culpabilidade, tida como o grau de reprovabilidade do comportamento, é ínsita ao tipo penal. O réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, de modo que, nesta fase, utilizo uma delas (autos n. 0002572-97.2014.8.26.0531), evitando-se, assim, o bis in idem (Súmula 241 do STJ). Ausentes provas acerca da conduta social do agente. A personalidade é circunstância neutra ante a falta de amparo probatório. O motivo do crime é próprio à espécie, assim como as suas circunstâncias e consequências. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Logo, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e tendo em vista o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes de pena. Lado outro, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), que é específica, diante da condenação definitiva imposta nos autos n. 0001284-09.2016.8.26.0996. Assim, agravo a pena intermediária em um sexto, fixando-a em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento.

Registre-se que não cabe, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente, o que, por si só, obsta a aplicação da benesse.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), ante a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante do teor do art. 33, §§2º, 'b', e 3º, do CP, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Tal cenário não resta alterado, por ora, pela aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Ainda em vista da natureza da infração, da reincidência e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, inviável a sua substituição por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional (art. 44, I e II, e 77, I, do CP, e art. 44 da Lei 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado Jonathas da Silva Moraes como incurso nas sanções do art. 33 da

Lei 11.343/06, à reprimenda de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Lado outro, porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, mantenho-a. Com efeito, enquanto o fumus comissi delicti resta verificado em sede de cognição exauriente, o periculum in libertatis é extraído da gravidade em concreto das condutas do réu, cujos antecedentes indicam a habitualidade delituosa e a periculosidade social, o que inequivocamente ocasiona severo e concreto risco à ordem pública. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I e II, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado. Recomende-se o réu à prisão.

Condene o acusado, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para a advogada indicada para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio. Expeçam-se as certidões de honorários.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos, e, com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos.

Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF), intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução, assim como o que mais for cabível.

P. I. C., com observância do art. 392 do CPP.

Catanduva, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA